

1501013-32.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo
Comarca: Diadema
Foro: Foro de Diadema
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/09/2022

... local. O celular era para ser usado no tráfico, e seria de emergência, para se comunicar com alguém. Já foi processado por tráfico, saiu de alvará, e no dia seguinte teve que pagar as drogas do primeiro tráfico, e então foi pego de novo. Logo, o interrogatório com a confissão parcial do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501013-32.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-32.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128790/2022 - 03º D.P. DIADEMA, 24914494 - 03º D.P.

DIADEMA, 2128790 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mike Daniel Pereira da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

MIKE DANIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 09 e 11/12, está sendo processado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2022, por volta das 21h00, na Avenida Maria Cândida de Oliveira, altura do nº 837, no bairro Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 88 embalagens contendo 45,08g da droga cocaína, 109 embalagens contendo 22,48g da mesma droga, na forma de crack, e 248 embalagens contendo 568,86g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 13/14 e laudo de constatação provisória de fls. 16/18,

agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que entre os dias 07 de abril de 2022 e 11 de maio de 2022, nesta comarca de Diadema, o acusado adquiriu e recebeu em proveito próprio, um telefone celular da marca Samsung, pertencente à vítima Natalia da Silva Souza Dias, coisa que sabia ser produto de crime. Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 43/46) e não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 25/05/2022 (fl.78). Certificada a citação positiva do Réu (fl. 92), foi nomeado Defensor Público, quem ofertou defesa inicial à fl. 97.

Nesta audiência uma foi ouvida uma testemunha comum, homologada a desistência das Partes com relação à faltante, e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade de drogas, com a atenuante da menoridade relativa e da confissão apenas para o tráfico, concordando com a redução da pena, mas em patamar mínimo, sem a substituição pela pena corporal pela restritiva de direitos, fixando-se regime prisional semiaberto, sem possibilidade do recurso em liberdade somado à perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória, especialmente no que tange à receptação do celular, de baixo valor monetário, sem que ele soubesse ser produto de ilícito. Subsidiariamente, requereu que as penas-base fossem fixadas no mínimo legal dada à primariedade do acusado, com a redução pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão, e o redutor máximo da pena do tráfico, afastando-se o concurso material do crime, mas somente a figura do art. 70 do CP, além da substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade ante a detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva do delito de tráfico vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.13/14, nos laudos de constatação e no definitivo (fls. 16/18 e 113/115), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína. E a materialidade do crime de receptação vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 31/32 referente ao crime antecedente, e pelo auto de exibição, apreensão e entrega do celular (fl. 21) roubado e localizado na posse do acusado. Ressalto que: na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente (STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.) A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

A Vítima não reconheceu o réu como sendo o roubador do seu aparelho celular, mas registrou ocorrência da subtração desse bem (fls. 31/32). Assim, devidamente demonstrado o crime anterior necessário ao delito de receptação.

Passo a análise das provas.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.07/08), informaram

que estavam em operação pelo bairro Casa Grande, em Diadema, em ponto conhecido pela traficância, oportunidade em que visualizaram o indiciado com uma pochete aparentemente na venda dos entorpecentes. Ao perceber que seria abordado, o suspeito empreendeu fuga, mas logo foi contido pelos policiais militares. Em busca pessoal localizaram na posse do acusado uma sacola e uma pochete contendo: 248 invólucros plásticos com substância esverdeada aparentando ser maconha, 88 invólucros com substância branca aparentando ser cocaína e 109 papelotes com material aparentando ser crack, todos embalados e individualizados para o comércio ilícito. Também foi apreendido com o indiciado o montante de R\$52,50, além de um celular Samsung que após consulta constou-se ser produto de roubo.

Sob o crivo do contraditório o policial Cesar Araujo Matias de Albuquerque declarou que o local é um ponto de venda de drogas. É um local com muitas vielas. Várias pessoas correram, inclusive o réu, quem estava com os entorpecentes e uma certa quantia em dinheiro e um aparelho celular que souberam ser produto de ilícito só no DP. O réu confessou o tráfico, e sobre o celular, disse que era dele. O réu era quem estava com uma pochete ao correr e os outros não estavam com nada na mão, por isso foram ao seu encalço. Reconhece o réu como sendo a pessoa que estava com as drogas e com o aparelho celular. Às reperguntas, disse que as drogas eram maconha, crack e cocaína, menos de um quilo, mas muitas porções embaladas para a venda. Continua patrulhando pela região e ali continua sendo um ponto de venda de drogas.

O policial Caio Teixeira Martins não foi ouvido em juízo, tendo dificuldade em participar da teleaudiência, tendo as Partes desistido de sua inquirição, o que foi homologado nessa data.

O réu, em solo policial (fl.09) confessou que vendia os entorpecentes pelos valores de R\$5,00 a R\$50,00, recebendo a quantia de R\$300,00 por dia, e quanto ao celular informou que adquiriu em data anterior de pessoa que não sabe dizer o nome.

Em juízo o acusado confessou que estava no ponto de drogas porque estava devendo drogas para o Comando e no primeiro dia que foi para paga-los, recebeu o celular para poder chamar os traficantes, pedir mais drogas, avisar se tinha viatura no local. O celular era para ser usado no tráfico, e seria de emergência, para se comunicar com alguém. Já foi processado por tráfico, saiu de alvará, e no dia seguinte teve que pagar as drogas do primeiro tráfico, e então foi pego de novo. Logo, o interrogatório com a confissão parcial do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Ora, o réu confessou inicialmente que estava no ponto de venda de drogas já conhecido, vendendo os entorpecentes, que foram apreendidos em seu poder, assim como o aparelho celular, produto de roubo, tendo ele dito que o adquirira em data anterior, de um desconhecido, sem dar maiores detalhes do valor e de como fora feita a negociação, e de quem seria essa pessoa, tanto que não tinha nota fiscal nem documentação do bem, ou mesmo recibo, de modo que tinha prévio conhecimento acerca da origem espúria do bem. E em juízo inovou, o que por si só já demonstra que mente, quando disse que o celular lhe fora dado para ser usado em caso de emergência, se precisasse de mais drogas e para avisar se havia viatura, embora alegue desconhecer se tratar de produto de ilícito. E que estava traficando para pagar uma dívida de drogas, de sua prisão anterior.

Mas não provou nada disso como lhe competia o ônus, ou seja, que fora coagido a praticar o tráfico para pagar uma dívida que tinha de drogas, e ainda assim o fosse, existem vários outros trabalhos lícitos que ele poderia ter feito para ganhar dinheiro e pagar o que fosse. E nem há prova de que desconhecesse a procedência ilícita do aparelho celular, porque primeiro disse que o adquirira em data anterior, de um desconhecido, para em juízo dizer que era o aparelho usado no tráfico em caso de emergência, e portanto, se recebido com as drogas, certa a procedência espúria, até porque não estaria em nome de um dos traficantes, que

assim seria descoberto e também indiciado por esse crime dos autos.

Ademais: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). E no presente caso não há prova da boa fé do réu.

Anoto que embora não tenha sido presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. E a dinâmica do recebimento do aparelho celular, juntamente com as drogas, para que pudesse falar com os traficantes, não deixa dúvida do conhecimento prévio de se tratar de bem espúrio e, pois, devidamente demonstrado o dolo em ambos os crimes.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das drogas (maconha e cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (R\$119,00), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

E, por fim, as circunstâncias que envolveram os fatos, a forma como se desenvolveu a conduta do agente e sua própria experiência e contradições acerca do recebimento do celular, revelam que ele agiu com dolo, e não culpa. Logo, diante de tais circunstâncias, é de se concluir que o réu sabia ser o celular receptado de origem ilícita. Vale lembrar que, consoante entendimento jurisprudencial, a constatação do dolo no crime de receptação se dá a partir das circunstâncias que envolvem os fatos e a conduta do acusado. Confira-se o seguinte excerto do presente julgado: [...]Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. (AgRg no REsp n. 908.826/RS, relatora Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do Tj/Mg), Sexta Turma, julgado em 30/10/2008, DJe de 17/11/2008).

Desta forma, a responsabilização do réu pelos crimes imputados na denúncia é mesmo de rigor, pois trata-se de réu detido em flagrante, de modo que a materialidade e a autoria encontraram amplo respaldo nas provas orais produzidas em contraditório, assim como o dolo.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar um aumento das penas, mas sim a grande quantidade de narcóticos apreendidos (445 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas e do princípio da proporcionalidade de quanto mais drogas maior a pena, fixo em primeira fase, as seguintes reprimendas: 06 anos de reclusão e 600 dias-multa para o delito de tráfico, e em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime de receptação.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e sim as atenuantes da menoridade relativa e da confissão parcial. Tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do decreto condenatório com relação ao crime de tráfico, apenas, reduzo a pena deste ao mínimo

legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Presente a atenuante da menoridade relativa do réu também para o delito de receptação, mas como a pena deste já foi fixada no mínimo legal, não se tem como ir aquém disso: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, consoante Súmula 231 do STJ. Anoto apenas não haver a atenuante da confissão da receptação, porque o réu não confirmou saber previamente da origem espúria do bem, mas ao assumir receber coisa juntamente com as drogas, para ser usada no tráfico, para se comunicar com traficantes, assumiu o risco de responder pelo crime, quanto mais sendo óbvio que o aparelho não estaria no nome de um dos traficantes para ser descoberto e indiciado juntamente com o acusado. Além de ser de conhecimento notório que aparelhos celulares se tornaram verdadeira moeda de troca em biqueiras.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de nenhuma das penas. Nem de redução para o crime de receptação. Apenas para o tráfico. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fl.38/39), mas considerando a apreensão dinheiro proveniente de efetivas vendas de drogas a usuários, disseminando e contribuindo com o vício, e pela natureza de maior parte das drogas, cocaína e crack, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, além do réu ter sido recém solto por tráfico, e nessa condições ter descumprindo medidas cautelares, tornando a vender drogas, entendo que o redutor de 1/6 é o razoável e proporcional à maior dedicação do réu à traficância ilícita, como se depreende inclusive da FA de fls. 38/40 a demonstrar que o réu faz do tráfico seu meio de vida, totalizando assim 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Finalmente, pela regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas obtidas, para tornar definitiva nessa instância, em 05 anos e 02 meses de reclusão e 426 dias-multa. Dito isso, afasto pedido subsidiário da Defesa quanto a aplicação do concurso formal de crimes, até por não se saber se o réu adquiriu o aparelho em data anterior, de um desconhecido, ou se juntamente com as drogas, já que ele trouxe ambas as versões, que não lhe favorece, não se podendo afirmar, portanto, como pretende a Defesa, que ele tenha recebido celular e drogas juntas, como pretende, mas não provou.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando não apenas a quantidade da pena, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida, como no presente caso (vide fls. 38/39, 40, 72/76).

Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos

33, caput e parágrafo 1o, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas (fls. 38/40) bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ademais (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra MIKE DANIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 09 e 11/12 pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e o faço para condená-lo à pena de 05 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, cada qual fixado em 1/30

do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível com o regime ora fixado. Oficie-se.

Sendo ele assistido pela DPE, beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de numerário apreendido nestes autos (fl.13 e 70), com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA